

1502596-09.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Do afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal

No tocante à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502596-09.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502596-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026771/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22719749 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2026771 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVAIR SANTOS ROSA

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EVAIR SANTOS ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 12h40min, durante período de calamidade pública na Rua Alfonso Santi, altura do nº 06, Capão Redondo, nesta capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 274 porções de cocaína, com peso líquido de 112,8g, 110 porções de "maconha" (Tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 254,6g, 170 pedras de "crack"

(cocaína), com peso líquido de 67,4g, 04 comprimidos de "ecstasy", com peso líquido de 1,7g, 06 frascos de "lança-perfume" (tricloroetileno), com volume líquido de 48ml, e 03 adesivos de "LSD", com peso líquido de 0,1g, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo de constatação de fls. 36/39 e laudo químico-toxicológico a ser juntado.

Consta da denúncia que, segundo o apurado, o denunciado trazia consigo e guardava, no interior de duas bolsas, os referidos entorpecentes para fins de entrega a terceiros.

É da inicial que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o denunciado entrando em uma viela carregando as referidas bolsas.

Ele, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga correndo, porém, foi detido, em seguida.

Extraí-se da exordial que no interior das bolsas foram encontradas 274 porções de cocaína, 110 porções de "maconha", 170 pedras de 'crack', 04 comprimidos de 'ecstasy', 06 frascos de 'lança-perfume', 03 adesivos de 'LSD', bem como R\$ 75,75, em espécie, além de um caderno de anotações e um aparelho celular.

É da inicial que diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e, ao ser interrogado (fls. 11), permaneceu em silêncio.

Por fim, é da denúncia que as circunstâncias em que o denunciado foi preso aliadas à grande quantidade e variedade de drogas apreendida, à forma como estavam embaladas, em porções individuais, ao encontro de relevante quantia de dinheiro e anotações, indicam que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.

Por decisão exarada aos 31 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 68/71).

O réu foi citado (fl. 158).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 162).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 03 de março de 2022 (fl. 164).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor. A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Laudo de Constatação (fls. 36/39), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 166/169), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultados dos Itens 1 e 3), tetrahidrocannabinol (resultado do Item 2), tricloroetileno (resultado do Item 4), tenanfetamina (resultado do item 5), substância 25B-NBOH(2-([2-(4-Bromo-2,5 dimetoxifenil)etil]amino)metil)fenol (resultado do item 6), Laudo Pericial das duas bolsas onde foram encontradas as drogas (fls. 152/155), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Mateus da Silva Santos, policial militar, narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento e foi avistado o indivíduo com uma bolsa em mão e ao tentar realizar a abordagem ele se evadiu pela viela. Foi realizada a abordagem a pé. Obtiveram êxito em realizar a abordagem. Encontraram entorpecentes e certa quantia em dinheiro. Tinha cocaína, maconha, lança-perfume, tinha pouca quantidade de crack e LSD. Não se recorda se o réu falou alguma coisa. Não conhecia o réu. O local é conhecido como ponto de venda de droga. As drogas estavam em uma bolsa que ele estava carregando e a bolsa foi apreendida. Também foi ouvida em juízo a testemunha Thiago Paiva Menetrie de Souza, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que em patrulhamento a equipe desembarcou e em pequena incursão pelo local avistaram o indivíduo que saiu correndo. Ao ser abordado foi encontrada certa quantia de drogas com ele, em uma bag, se não se engana. Lembra de cocaína e maconha, se não se engana. Não se recorda a quantidade. Não se recorda se tinha dinheiro, caderno com anotações. Não conhecia o réu. No local o réu estava sozinho, era uma viela. Não se recorda se as drogas estavam distribuídas em duas bolsas.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que tem ciência da condenação por tráfico em processo da 17ª Vara Criminal. Saiu de alvará em 08/12/2021. Mora sozinho. Estudou até o oitavo ano. Parou de estudar para trabalhar. Estava trabalhando como auxiliar geral em uma lanchonete, sem registro em carteira. Conhecia o policial Matheus porque ele fez a sua primeira prisão. Prefere ficar em silêncio com relação à acusação destes autos.

Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais militares, a condenação do Réu se impõe, salientando-se que a alegação apresentada pelo réu de que conhecia o policial Matheus restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se que apesar de o Réu ter alegado em seu interrogatório colhido em juízo que já conhecia o policial Matheus porque ele teria feito a sua primeira prisão, depreende-se da denúncia oferecida em desfavor do Réu nos autos da 17ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo que os policiais militares ali arrolados são diversos (Alexandre da Silva Jacyntho e Adair César Lourenço), conforme folhas 170/174.

Registre-se, ainda, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, testemunhas compromissadas como as demais, sendo certo que a ilustre Defensoria não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Além disso, a finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha, crack, lança-perfume, tenanfetamina e a substância 25B-NBOH(2-([2-(4-

BROMO-2,5 dimetoxifenil) etil]AMINO}METIL)FENOL); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário ((274 invólucros contendo cocaína, 110 invólucros contendo maconha, 170 invólucros contendo pedras de crack, 6 frascos contendo substância tricloroetileno, 4 comprimidos de droga conhecida por ecstasy e 3 adesivos contendo droga conhecida por LSD); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas; d) pela apreensão de R\$ 75,75 em dinheiro – fls. 5/6 e, e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, registrando-se a variedade e a natureza de entorpecentes, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Do afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos” (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021). (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021, e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu, apesar de já ostentar condenação anterior (sentença condenatória de 07/12/2021) em primeira instância pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), em processo da 17ª Vara Criminal, consoante certidão acostada as fls. 116/117, deve ser considerado primário nestes autos, uma vez ausente trânsito em julgado anterior ao cometimento do delito ora apurado, praticado em 30/01/22. Registre-se, no entanto, que a grande quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas (274 invólucros contendo cocaína, 110 invólucros contendo maconha, 170 invólucros contendo pedras de crack, 6 frascos contendo substância tricloroetileno, 4 comprimidos contendo droga tenanfetamina e 3 adesivos contendo droga conhecida por "LSD"), deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº

11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas torno pena final.

Insta salientar não ser possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, posto que a grande quantidade, natureza e a variedade de droga apreendida com o Réu (maconha, cocaína, crack, tricloroetileno, tenanfetamina e "LSD") pouquíssimo tempo após ter sido beneficiado com alvará de soltura nos autos do processo da 17ª Vara Criminal, onde havia sido condenado em primeira instância em dezembro de 2021 por crime de tráfico de drogas estão a demonstrar a ligação do réu com o crime.

Nesse passo, são elucidativos os julgados colacionados abaixo:

"(...) Por fim, deixo de aplicar a causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade de droga apreendida e seu formato (tabletes) estão a demonstrar que o acusado se dedica a atividades ilícitas e mantém estreito relacionamento com organizações criminosas, pois o fornecimento de tal quantidade de droga não ocorre facilmente em qualquer esquina". - Apelação Criminal nº 989.678.3/7 - Relator Vinicius de Toledo Piza Peluso. E ainda consoante elucidativos julgados: Apelação Criminal nº 1.034.329.3/8 - Relator Luiz Toloza Neto; Apelação Criminal nº 1.089.991.3/5 - Relator Pinheiro Franco; Apelação Criminal nº 1.100.879.3/2 - Relator Marcos Zanuzzi. (grifos nossos)

Do regime de cumprimento de pena:

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se a considerável quantidade, variedade e natureza das drogas que o réu trazia consigo, a denotar que não se tratava de modesto tráfico.

Pelas mesmas razões e também em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos se mostra inviável, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu EVAIR SANTOS ROSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento da multa no valor de 583 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, sendo incontroverso o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 8ª Edição: "...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão." O Réu foi preso em flagrante nestes autos na data de 30/01/2022 e tinha sido beneficiado nos autos do processo da 17ª Vara Criminal da Capital com alvará de soltura na data de 08/12/2021, processo em que foi condenado em primeira instância pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas).

Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido as fls.

05/06 - R\$ 75,75, em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº

04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA